

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1390/2555

พนักงานอัยการจังหวัดสกล
นายสวัสดิ์ เนยตะขบ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277

ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขใหม่โดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 เป็นเพียงการขยายขอบเขตของการกระทำชำเราในส่วนของอวัยวะที่ถูกกระทำ ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อวัยวะเพศ จะเป็นทวารหนักหรือที่ช่องปากก็ได้ และสิ่งที่ใช้ในการกระทำไม่จำเป็นต้องเป็นอวัยวะเพศ เท่านั้น จะเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ ดังนั้น การกระทำชำเราไม่ว่าเป็นการกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นจึงยังคงต้องมีการสอดใส่อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดให้ล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เพียงการสัมผัสภายนอกกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นไม่ว่าด้วยอวัยวะส่วนใดหรือด้วยวัตถุสิ่งใดก็จะเป็นการกระทำชำเราไปเสียทั้งหมด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277, 283 ทวิ, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม, 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีกับฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 14 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าไปเพื่อการอนาจาร จำคุก 6 ปี รวมจำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก จำคุก 4 ปี เมื่อรวมกับโทษในความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าไปเพื่อการอนาจารตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว รวมจำคุก 10 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่มีได้โต้เถียงกันฟังเป็นยุติว่า จำเลยพาและพรากผู้เสียหายที่ 1 อายุ 5 ปีเศษไปเพื่อการอนาจาร แล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลยเสียดสีถูไถกับอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 จนสำเร็จความใคร่ ความผิดฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร และฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง

มีปัญหาข้อกฎหมายวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า การที่จำเลยใช้
อวัยวะเพศของจำเลยเสียดสีถูไถกับอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 เป็นการกระทำ
ชำเราผู้เสียหายที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า การกระทำชำเราตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 277 วรรคแรก หมายถึง การร่วมประเวณี กรณีจึงต้องมีการสอดใส่อวัยวะ
เพศของผู้กระทำเข้าไปในอวัยวะเพศของอีกฝ่าย แม้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคสอง ซึ่งแก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 บัญญัติว่า "การกระทำชำเราตามวรรคหนึ่ง
หมายความว่า การกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของ
ผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใด
กระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น" ก็เป็นเพียงการขยายขอบเขตของ
การกระทำชำเราในส่วนของอวัยวะที่ถูกกระทำในมาตรา 277 วรรคแรก ไม่จำเป็นต้อง
ต้องเป็นที่อวัยวะเพศ จะเป็นทวารหนักหรือที่ช่องปากก็ได้ และสิ่งที่ใช้ในการกระทำ
หรือไม่จำเป็นต้องเป็นอวัยวะเพศเท่านั้น จะเป็นสิ่งอื่นใดก็ได้ ดังนั้น การกระทำชำเรา
ไม่ว่าเป็นการกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่นจึงยังคงต้องมี
การสอดใส่อวัยวะเพศหรือสิ่งอื่นใดให้ล่งล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือช่อง
ปากด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเพียงการสัมผัสภายนอกกับอวัยวะเพศ ทวารหนักหรือ
ช่องปากของผู้อื่นไม่ว่าด้วยอวัยวะส่วนใดหรือด้วยวัตถุสิ่งใดก็จะเป็นการกระทำชำเรา
ไปเสียทั้งหมด คดีนี้จำเลยเพียงใช้อวัยวะเพศของจำเลยเสียดสีถูไถกับอวัยวะเพศ
ของผู้เสียหายที่ 1 แม้โดยมีเจตนาเพื่อสนองความใคร่ของจำเลย แต่เมื่อมิได้มีการ
สอดใส่เพื่อที่จะให้อวัยวะเพศของจำเลยล่งล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1
จึงยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นการกระทำชำเรา การกระทำของจำเลยคงเป็นเพียงกระทำ
อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก คำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ภาค 3 ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

(วิรุพหิ์ แสงเทียน-ปดาร์ณิ ลัดพลี-ฉัตรไชย จันทรพรายศรี)

ศาลจังหวัดสืคิ้ว - นายศรีสิทธิ์ เหลืองคุณวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1757/2553

ต้น

หมายเหตุ